

故意に関する次の各【見解】に従って後記1から5までの各【事例】における甲の罪責を検討した場合、いずれの【見解】に従うかによって、結論が異なるものはどれか。

【見 解】

A説：行為者が認識していた事実と発生した事実とが、構成要件の評価として一致する限り、発生した事実についての故意が認められ、殺人罪においては、客体が「およそ人」という点で一致していれば故意が認められる。

B説：行為者が認識していた事実と発生した事実とが、具体的に一致しない限り、発生した事実についての故意は否定され、殺人罪においては、客体が「その人」という点で一致していなければ故意は認められない。

【事 例】

1. 甲は、Vを殺そうと考えてVの首を絞め、Vが動かなくなったので死亡したものと思い、Vを海岸の砂上まで運び放置したところ、Vが砂を吸引したことにより死亡した。
2. 甲は、Vが連れている犬を殺そうと考え、その犬を狙って猟銃を発射したが、犬をかばおうとしたVに弾丸が当たり、Vを死亡させた。
3. 甲は、前方を歩いていた人をV1と思い、V1を殺そうと考え、その人を狙って拳銃を発射し弾丸を命中させて死亡させたが、その人はV1ではなく、V2であった。
4. 甲は、Vから殺してほしいと頼まれたので、Vを殺そうと考え、Vの首を絞めてVを死亡させたが、嘱託殺人が犯罪にならないと考えていた。
5. 甲は、V1を殺そうと考え、V1を狙って拳銃を発射したが、弾丸がそれて、V1ではなく、そのそばにいたV2に当たり、V2を死亡させた。

No.1	故意	正答率
予備H30-4	正解	79%
	5	

法定的符合説とは、認識事実と実現事実とが、構成要件の評価として一致（符合）する限度で、実現事実についても故意責任を認める立場である。つまり、認識事実と実現事実がいずれも同一の構成要件に該当する事実である場合は、実現事実に対する故意犯が成立することになる。これに対し、具体的符合説とは、認識事実と実現事実とが具体的に一致（符合）しない限り実現事実について故意責任を認められないとする立場である。本問のA説は法定的符合説、B説は具体的符合説の説明である。

1 結論が異なるない

本事例では、甲はVを絞殺したものと思っていたが、実際にはVを海岸の砂上まで運び放置したためVが砂を吸引したことにより死亡している。すなわち、甲にはV死亡の因果関係に錯誤がある。このように、行為者が自己の行為（第一行為）により結果を発生させたと考えていたが、実際にはその後の行為（第二行為）により結果が発生したという因果関係の錯誤の事例を、「ウェーバーの概括的故意」事例という。本事例において、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）いずれの見解からも、甲が認識した絞殺によるVの死亡という因果経過と実際に発生した窒息によるVの死亡という因果経過は、ともに殺人罪における法的因果関係の範囲内にあるといえる。よって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）のいずれによっても、甲に殺人罪の故意が認められ、甲には殺人罪が成立する。したがって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）によって結論は異なるない。

なお、大判大12.4.30（百選I15事件、因果関係の錯誤）は、本事例と同様の事案において、第一行為と結果との因果関係が存在し、第二行為によって因果関係は遮断されないとして、因果関係を肯定し殺人罪（199条）の故意を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、現実の因果経過（砂末吸引による死）も認識・予見した因果経過（絞扼による死）も、ともに殺人罪の構成要件に該当し、法的因果関係の範囲内にあるので故意は阻却されないということを挙げている。

2 結論が異なるない

本事例では、甲が認識・予見していた事実は犬の死亡であるが、発生した事実はVの死亡である。犬を殺すことは器物損壊罪（261条）に当たり、殺人罪（199条）とは別の構成要件に当たる。このように、行為者が認識していた犯罪事実と現実には発生した犯罪事実とが構成要件を異にする場合を抽象的事実の錯誤という。

A説（法定的符合説）からは、抽象的事実の錯誤がある場合、発生した事実については原則として故意が認められないが、例外的に、認識していた事実と発生した事実の構成要件が重なり合う場合に、その限度でいずれか軽い方の事実について故意が認められる。そして、法定的符合説を採用する判例・通説は、この構成要件の重なり合いを実質的に判断している。具体的には、行為態様の共通性かつ保護法益の共通性によって判断される。本事例においては、器物損壊罪は財産に対する罪であるのに対して、殺人罪は生命に対する罪であり、保護法益が異なる。よって、器物損壊罪と殺人罪に構成要件の実質的重なり合いは認められず、殺人罪の故意は認められない。また、器物損壊罪には未遂の処罰規定がないので不可罰である。もっとも、甲には過失が認められるから過失致死罪が成立する。

B説（具体的符合説）からは、甲が器物損壊罪の故意で殺人罪を犯している以上、認識事実と実現事実とが具体的に一致しているとはいえず、殺人罪の故意は認められない。また、器物損壊罪には未遂の処罰規定がないので不可罰であるが、甲には過失が認められるから過失致死罪（210条）

が成立する。

したがって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）によって結論は異ならない。

3 結論が異なる

本事例では、甲が認識・予見していた事実は、V1の死亡であるが、発生した事実はV2の死亡である。このように、認識・予見した事実と発生した事実が同じ構成要件に該当する事実である場合を具体的事実の錯誤という。そして、行為者が狙い通りの客体に法益侵害結果を発生させたが、行為者が思っていた客体ではなかった場合を客体の錯誤という。

A説（法定的符合説）からは、甲が認識していたV1の死亡も発生したV2の死亡も、客体が「およそ人」という点で共通しているから、甲には殺人罪の故意が認められる。よって、甲には殺人罪が成立する。

B説（具体的符合説）からは、甲が認識・予見していた事実はV1の死亡であり、発生した事実はV2の死亡であるので、一致しておらず、V2の死亡に対して殺人罪の故意が欠けるとも思える。しかし、甲は前方を歩いていた「その人」を狙って、「その人」を死亡させているから、被害者は「その人」の限度で一致しており、「その人」に対する甲の殺人罪の故意が認められる。よって、甲には、V2に対する殺人罪の故意が認められる。よって、甲には殺人罪が成立する。

したがって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）によって結論は異なる。

4 結論が異なる

38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減輕することができる。」としている。

行為者が錯誤によって違法性の意識を欠くことを、法律の錯誤という。法律の錯誤は、①刑罰法規が当該行為を禁止していること自体を知らない、法律の不知の場合と、②刑罰法規の解釈を誤った、あてはめの錯誤の場合の2種のいずれかの原因によって生じる。本事例では、甲は嘱託殺人罪（202条後段）の構成要件に該当する行為を行っているが、嘱託殺人が犯罪にならないと考えているので、①法律の不知に当たる。法律の錯誤がある場合に故意が認められるか否かは、違法性の意識の可否をどう考えるかに影響される。違法性の意識必要説に立つ場合、甲は違法性の意識がないから、故意が認められない。違法性の意識不要説に立つ場合、甲に違法性の意識がなくとも、故意が認められる。違法性の意識を欠いたことにつき相当の理由があれば故意が認められないとする違法性の意識可能性必要説に立つ場合、法律の不知の場合には原則として違法性の意識の可能性を肯定することができるから、甲が嘱託殺人が犯罪にならないと考えたことにつき相当の理由がない限り、故意が認められる。

まず、違法性の意識必要説に立ち、故意を認めなければ、A説、B説のいずれの見解に立つにせよ、過失犯の成立が問題となるのみとなる。次に、違法性の意識必要説に立たずに、故意を認めるときは、甲は嘱託を受けてVを殺す認識で実際にVを殺している以上、A説、B説のいずれの見解に立つにせよ、嘱託殺人罪の故意は認められる。したがって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）によって結論は異なる。

5 結論が異なる

本事例において、まず、A説（法定的符合説）からは、V1に対しては、V1を殺そうと考え、V1を狙って拳銃を発射しているが、V1死亡の結果は発生していないため、殺人未遂罪（203条、199条）が成立する。V2に対しては、甲が認識していたV1の死亡も発生したV2の死亡も、客体が「およそ人」であり、殺人罪の構成要件に該当する事実であるから、実現した事実に対する故意は阻却されず殺人罪が成立する。

B説（具体的符合説）からは、V1に対しては、A説（法定的符合説）と同様に、殺人未遂罪が成立する。V2に対しては、甲が認識した客体であるV1と結果が発生した客体であるV2は同一

の客体ではなく、「その人」という点で一致しない。よって、甲に故意が認められず、殺人罪は成立しない。もっとも、V2の存在が予見可能であった場合は、過失致死罪が成立し得る。

したがって、A説（法定的符合説）とB説（具体的符合説）によって結論が異なる。